

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2012/13740

- Acusados: Carlos Alexandre Bonatti
Hoje Participações Investimentos S/C Ltda.
- Ementa: Não realização obrigatória de Oferta Pública de Aquisição de Ações por alienação de controle. Absolvição e multa.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:
1. ABSOLVER **Carlos Alexandre Bonatti** da imputação de responsabilidade pela não realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações, em suposta infração aos artigos 254-A da Lei nº 6.404/76 e 29 da Instrução CVM nº 361/02; e
 2. APLICAR à companhia **Hoje Participações Investimentos S/C Ltda.** a **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00** pela não realização obrigatória de Oferta Pública de Aquisição de Ações, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 254-A da Lei nº 6.404/76 e no art. 29 da Instrução CVM nº 361/02.

A companhia punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, a decisão absolutória transita em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados e o representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2012/13740

Acusados: Hoje Participações Investimentos S/C Ltda.
Carlos Alexandre Bonatti

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade pela não realização de oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle, em infração ao disposto nos artigos 254-A, da Lei nº 6.404/76, e 29, da Instrução CVM nº 361/02, em decorrência da aquisição do controle acionário da CELM – Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I – Do Objeto.

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários em 21.02.2013¹ (“Acusação” ou “SRE”), em face de Hoje Participações Investimentos S/C Ltda. (“Hoje Participações”) e Carlos Alexandre Bonatti (conjuntamente denominados “Acusados”), para apurar a eventual responsabilidade pelo descumprimento do art. 254-A da Lei nº 6.404/76² e do art. 29 da Instrução CVM nº 361/02³, por não terem realizado oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) em decorrência da alienação do controle acionário da CELM – Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos (“CELM” ou “Companhia”).

II – Dos Fatos.

2. No dia 07 de julho de 2009, E.M.A.M., vice-presidente do conselho de administração da CELM à época, enviou correspondência à BM&FBovespa por meio da qual informou que o controle acionário da CELM teria sido transferido à Hoje Participações em 07 de janeiro de 2009, tendo sido tal transferência formalizada por meio dos termos de transferência de ações nº 59 e 60 (“Termos de Transferência de Ações”) constantes da página 30 do Livro de Registro de Transferência de Ações da Companhia (fls. 16)⁴.

3. Após receber o documento, a bolsa enviou ofício⁵ à Companhia para que se manifestasse sobre (i) a quantidade total de ações de emissão da Companhia adquiridas pela Hoje Participações, (ii) o preço pago por ação e condições de pagamento para aquisição do controle acionário da CELM; (iii) preço por ação e condições de pagamento a ser ofertado aos demais acionistas minoritários em oportuna oferta de compra de ações com base no art. 254-A da Lei nº 6.404/76. Adicionalmente, informou que os negócios com as ações de emissão da CELM estariam suspensos a partir do pregão de 08.07.2009 no aguardo da resposta da Companhia.

4. Em resposta⁶, a Companhia confirmou a aquisição, pela Hoje Participações, de 110.216 ações de emissão da Companhia, que seriam equivalentes a 95,014% do capital social, pelo preço de R\$15,51 por ação. Afirmou, ainda, que “*em oportuna oferta pública de compra de ações e em cumprimento ao disposto no artigo 254-A da Lei nº 6.404/76, a Empresa, pretende adquirir, à vista, as ações que circulam no mercado, oferecerá aos demais (sic) acionistas minoritários que, juntos, representam 4,986% do capital social da Companhia, o valor previsto e assegurado no referido artigo da Lei que rege as Sociedades de Capital Aberto*” (fls. 20-21).

5. A fim de apurar a obrigatoriedade de realização de OPA em decorrência da operação, em 11.08.2009 foi instaurado pela SRE o Processo CVM nº RJ2009/7561, tendo sido enviado ofício⁷ à Companhia para que se manifestasse sobre a não realização da OPA e, adicionalmente, foram solicitados (i) todos os contratos de compra, venda e/ou transferência dos valores mobiliários envolvidos na operação e informações sobre eventuais aquisições posteriores feitas pelo novo controlador; e (ii) quadros contendo a estrutura de capital da CELM, antes e após as referidas operações.

6. Em 23.02.2010, a CELM apresentou resposta, assinada por Carlos Alexandre Bonatti, na qualidade de diretor-presidente da CELM, da qual se destacam as seguintes afirmações (fls. 25-27):

- a. *"Em relação ao contrato de compra e venda firmado entre os antigos acionistas e a Empresa Hoje Participações Investimentos S/C Ltda., por contemplar cláusula de confidencialidade, expomos a seguir dados comerciais que constam do aludido contrato: Data de Celebração: 07.01.2009; Ações adquiridas: 110.216; Valor por ação: R\$ 15,43".*
- b. *desde já informamos que a Empresa Hoje Participações tornou-se controladora, após adquirir dos acionistas P.A.M.; E.M.A.M.; V.P.M.A.M.; e I.M.M.A.M. o total de 110.216 ações, correspondente a 95,014% [do capital votante da CELM]". (fls. 28)*

7. Juntamente com a resposta, a Companhia encaminhou parecer jurídico, cujos principais argumentos são transcritos abaixo (fls. 28-36):

- a. *"Tal como informado pela consulente, na data de 07.01.2009 foi celebrado contrato para a venda e compra das ações de seu quadro, entre P.A.M., E.M.A.M., V.P.M.A.M. e I.M.M.A.M., na qualidade de cedentes e Hoje Participações e Investimentos S/C Ltda."; (fls. 29)*
- b. *"(...) daqueles que cederam suas ações [à Hoje], nenhum possuía o controle acionário da companhia, sendo que esta posição de controle foi alcançada pela adquirente apenas pelo fato de ter amalhado, de vários acionistas, suas respectivas ações"; (fls. 29)*
- c. *"(...) cumpre observar que a Consulente, antes da operação de venda e compra de ações pela Hoje Participações e Investimentos S/C Ltda., constituía Companhia na qual não existia uma estrutura de poder consolidada, seja por não haver um acionista majoritário, seja em razão de não existir um bloco de acionistas vinculado por acordo de acionistas, com a finalidade de exercerem, com exclusividade, o domínio sobre a atividade empresarial da Sociedade." (fls. 34)*
- d. *"concluimos no sentido de que não houve violação legal e tampouco inobservância de Instruções da CVM, em especial a 361/2002, na transação de venda e compra das ações pela Hoje Participações e Investimentos S/C Ltda., que passou a deter controle acionário da CELM – Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos, sem a oferta pública de ações aos minoritários, vez que a aquisição deste poder decorreu de forma originária, entendimento que se harmoniza com a redação do artigo 254-A da Lei n. 6.404/76 e com o entendimento do Colegiado da CVM". (grifos do autor) (fls. 35)*

8. Considerando que os questionamentos feitos pela área não foram plenamente satisfeitos, a SRE enviou outros ofícios⁸ a fim de obter maiores esclarecimentos da CELM sobre a situação e, não tendo obtido êxito, em 26.09.2011, a GER-1 encaminhou o Processo CVM nº RJ2009-7561 à SRE, manifestando o entendimento de que a operação realizada "enseja OPA por

alienação de controle de CELM, nos termos do art. 254-A da Lei nº 6.404 e do art. 29 da Instrução CVM nº 361/02", propondo o envio do processo à área de *enforcement* para que avaliasse a propositura de termo de acusação em face da Hoje Participações (fls. 56-57).

9. No dia 25.10.2011 os Acusados foram intimados⁹ para, nos termos do art. 11¹⁰, parágrafo único, II, da Deliberação CVM nº 538/08, se manifestarem sobre suposta infração aos artigos 29 da Instrução CVM nº 361/02 e 254-A da Lei nº 6.404/76, assim como informar nome e endereço para envio de intimações.

10. Em resposta¹¹, Carlos Bonatti, em nome da CELM, reiterou as informações já prestadas no sentido de que a OPA não seria obrigatória, conforme parecer jurídico juntado aos autos (fls. 28-36). Entretanto, se colocou à disposição para *"acatar e seguir as orientações (...) no sentido de promover OPA com o fechamento de Capital, assim regularizando esta pendência"*.

11. Considerando que o Acusado não informou o endereço da Hoje Participações para o recebimento de intimações, no dia 10.08.2012, a SRE intimou¹² Carlos Bonatti novamente no endereço da Hoje Participações constante do cadastro da Receita Federal para, sob pena de multa, manifestar-se sobre a suposta infração e informar *"(i) nome e endereço para o envio de intimações e qualificação completa das pessoas física e jurídica ora intimadas, bem como os seus respectivos endereços eletrônicos, caso desejassem receber informações por esse meio; e (ii) nome e qualificação completa do sócio e/ou administrador da HOJE responsável pela alienação de que se trata"*.

12. No dia 16.08.2012, a SRE recebeu correspondência eletrônica em nome de C.D.L. (fls. 85), informando que o endereço a que foi destinada a segunda intimação não pertence à Hoje Participações, e sim à C.D.L. Tal situação ensejou o envio de novo ofício¹³ aos Acusados, direcionado à sede da CELM, por meio do qual foram reiterados os termos da segunda intimação.

13. Por fim, no dia 31.08.2012, Carlos Bonatti respondeu à segunda intimação, oportunidade em que reiterou suas respostas anteriores, colocando-se disposto a realizar a OPA (fls. 90).

III – Da Acusação (fls. 114-123).

14. A SRE, diante dos fatos acima expostos, propôs a responsabilização da Hoje Participações e do seu sócio administrador, Carlos Alexandre Bonatti, em decorrência da aquisição do controle acionário da CELM sem a realização de OPA como determinam os artigos 254-A da Lei nº 6.404/76 e o 29 da Instrução CVM nº 361/02.

15. De acordo com a Acusação, a CELM já possuía controlador definido anteriormente à operação realizada em 07.01.2009, ocasião em que foram alienadas ações à Hoje Participações e em que esta passou a deter o controle acionário da CELM. Sustenta a SRE que *"a partir da afirmação da CELM de que a HOJE adquiriu 110.216 ações ordinárias, correspondendo a 95,014% do capital social daquela companhia (cf. item 8.b), conclui-se, por mero cálculo aritmético, que este era composto por 116.000 ações ordinárias. Vale notar que esse quantitativo também é confirmado pelo IAN mais recente daquela companhia, disponível no IPE (cf. item 26 abaixo)"*¹⁴.

16. Aponta, assim, que sendo o capital social da Companhia composto por 116.000 ações ordinárias, P.A.M., proprietário de 87.651 ações, conforme consta no termo de transferência nº 59 (fls. 16), deteria participação de 75,5% do capital votante da CELM, não restando, portanto, quaisquer dúvidas, para a SRE, de que P.A.M. era, anteriormente à operação com a Hoje Participações, o acionista controlador da CELM.

17. Ademais, a SRE apontou que P.A.M. foi eleito, nas assembleias gerais extraordinárias realizadas em 11.05.2004 e de 15.12.2006¹⁵, como presidente do Conselho de Administração da CELM (fls. 94-100). Ainda, observou a Acusação que P.A.M. foi indicado no IAN da Companhia de 2006 como controlador da Companhia, por já possuir, àquela época, 52% das ações ordinárias de sua emissão (fls. 93)¹⁶.

18. Sobre o conteúdo do parecer jurídico juntado pelo Acusado, a SRE sustentou que as afirmações não se coadunam com a documentação constante dos autos. *"Ao contrário, nos Termos de Transferência de Ações somente constam dois dos acionistas citados no parecer jurídico: o Sr. P.A.M. e a Sra. E.M.A.M., sendo o primeiro o antigo controlador da CELM, conforme acima demonstrado"*. Conclui, portanto, que *"resta demonstrado que, por meio da transação realizada em 07.01.2009, houve a efetiva transferência do controle da CELM, antes exercido pelo Sr. P.A.M. para a HOJE"* (fls. 120).

19. Dessa forma, a Acusação afirma que tendo em vista que o novo controlador da CELM não formulou a OPA prevista no art. 254-A da Lei nº 6.404/76, resta configurada a infração ao art. 29 da Instrução CVM nº 361/02.

20. Com relação à autoria da infração, a Acusação entendeu que a responsabilidade pela ocorrência da infração ao art. 254-A da Lei nº 6.404/76, bem como ao disposto no art. 29 da Instrução CVM nº 361/02, deveria recair, primariamente, sobre a Hoje Participações. Em sua visão, nos termos do §1º do art. 29 da Instrução CVM nº 361/02, a obrigação de formulação de OPA prevista no *caput* desse dispositivo se dirigiria à sociedade adquirente do controle de companhia aberta. E, além disso, seria incontroverso que a referida sociedade teria passado a deter o controle da CELM, o que teria sido, inclusive, reconhecido pelo seu diretor responsável, que, em uma das correspondências enviadas à CVM, afirmou que *"a Empresa Hoje Participações tornou-se controladora [da CELM], após adquirir (...) o total de 110.216 ações, correspondente a 95,014% [do capital votante da CELM]"*.

21. Assim, a área conclui que o pedido de registro de OPA deveria ter sido formulado pela Hoje Participações, o que não ocorreu e, desta forma, a Hoje Participações deveria ser responsabilizada pela sua conduta omissiva.

22. Com relação à responsabilidade do diretor da Hoje Participações, Carlos Alexandre Bonatti, entendeu a Acusação que esta seria manifesta, na medida em que as sociedades só atuam por intermédio de seus órgãos, dentre os quais a diretoria, e estes realizam a vontade das pessoas naturais que os integram. O Acusado, na qualidade de diretor da adquirente, seria a pessoa física responsável pela condução dos atos praticados em nome da sociedade, bem como a pessoa que efetivamente deveria atuar para que a companhia cumprisse suas obrigações legais e regulamentares, sendo que a responsabilização de diretores por condutas atribuídas primariamente às sociedades que dirigem não seria novidade no âmbito da CVM¹⁷.

23. A Acusação afirma que *"mostra disso é que o Sr. Carlos Alexandre Bonatti, ao subscrever carta da CELM em resposta a ofício enviado pela BM&FBovespa, (a) reconhece que houve a aquisição do controle desta companhia (95,014% do seu capital social) pela Hoje, (b) informa o preço por ação praticado na operação (R\$ 15,51) e (c) reconhece a necessidade de realização de OPA, em atendimento ao art. 254-A da Lei nº 6.404/76 (...)"*.

24. Além disso, segundo a SER, a assinatura constante no campo *cessionário* dos Termos de Transferência de Ações (fls. 16) seria a mesma apresentada por Carlos Bonatti em suas cartas respostas aos ofícios enviados pela CVM, o que seria prova suficiente de que o ato que formalizou a aquisição do controle da CELM pela Hoje Participações foi praticado por meio do seu diretor, Carlos Bonatti. Destacou a Acusação, ainda, que, conforme cadastro do SERPRO, Carlos Bonatti seria o responsável pela Hoje Participações, *"de modo que a ele caberia atuar, em nome da HOJE, para que esta adotasse os procedimentos requeridos pela Instrução CVM nº 361/02"*.

25. Portanto, para a SER, teria restado caracterizada a conduta omissiva do diretor, que, na qualidade não só de diretor, mas, também de responsável pela adquirente, não teria tomado as providências cabíveis para que a Hoje Participações, na condição de nova controladora da CELM, realizasse o procedimento previsto no art. 254-A da Lei nº 6.404/76 e regulamentado pelo art. 29 da Instrução CVM nº 361/02.

26. Por fim, a Acusação registrou os seguintes esclarecimentos adicionais:

45. *A mero título informativo e considerando (i) que de acordo com as informações prestadas pela CELM em resposta ao ofício enviado pela BM&FBovespa, a HOJE teria adquirido 110.216 ações¹⁸ ordinárias de emissão da CELM, a um preço de R\$ 15,51 (fl. 20) e (ii) que o capital social da CELM era composto por 116.000 ações ordinárias, tem-se que a OPA atingiria um montante de R\$ 71.767,87 [percentual de tag along x (total de ações que compunham o capital social da CELM - ações adquiridas pela Hoje) x preço por ação praticado na operação de alienação de controle].*

46. *Ainda no tocante ao preço por ação que seria praticado em eventual OPA, em que pesem todas as diligências efetuadas pela SRE, informamos que não é possível precisar tal valor, tendo em vista que as informações prestadas a esta autarquia foram escassas e incongruentes, conforme se verifica nos itens 7.a e 40.b acima.*

47. *Quanto ao número de acionistas titulares das ações de emissão da CELM remanescentes em circulação, informamos que não é possível apurar, com base nos dados constantes no processo, a sua quantidade.*

48. *Informamos ainda que, enquanto companhia aberta, a CELM possuía suas ações listadas para negociação na BM&FBovespa.*

27. É importante ressaltar que, no dia 04.01.2010, o registro da CELM foi suspenso por ter descumprido, por período superior a 12 meses, as suas obrigações periódicas, previstas na Instrução CVM nº 480/09, tendo o registro sido cancelado de ofício em 04.01.2011.

IV Da Manifestação da Procuradoria (fls. 109-111).

28. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11¹⁹ da Deliberação CVM nº 538/08²⁰, com exceção do disposto no inciso IV do

art. 6º, que estabelece que no relatório devem constar “os dispositivos legais ou regulamentares infringidos”.

29. Com relação ao referido requisito, a PFE entendeu que o art. 29 da Instrução CVM nº 361/02 regulamentaria o disposto no art. 254-A da Lei nº 6.404/76 e, por ser este último hierarquicamente superior, deveria ser a primeira versão do termo de acusação ajustada a fim de incluir como dispositivo legal violado o referido artigo da lei societária, o que foi acatado pela Acusação.

V – Da Defesa (fls. 137-140).

30. Os Acusados, em defesa conjunta protocolada em 08.04.2013, afirmam inicialmente que não teria havido dolo, má-fé ou vontade de prejudicar alguém em benefício próprio e que não teriam recebido orientação certa e segura quanto a real necessidade de realizar OPA, tendo se colocado à disposição para realizá-la desde que a CVM os orientasse.

31. Defendem que estiveram na sede da CVM a fim de buscar informações acerca dos procedimentos necessários para realizar o procedimento, tendo sido orientados a procurar um advogado para auxiliá-los e, ao consultar o especialista, foi emitido parecer no sentido de que a OPA não seria necessária.

32. Sustentam que não tiveram a intenção de prejudicar os acionistas da Companhia e teriam tentado identificar e contatar os demais acionistas, sem êxito. Além disso, afirmaram que a Companhia estaria “*trabalhando com PL negativo, sem lucro e consumindo seus recursos, na expectativa de sobreviver e tentar, um dia, equalizar sua condição financeira. A análise de seus números deixa claro que a CELM não é nem de longe um investimento para quem quer que seja*”.

33. Ainda, a defesa retoma o argumento de que teria ocorrido uma aquisição originária, uma vez que “*o controle da empresa estaria concentrado em uma única entidade familiar (família Marques), levando ao cristalino entendimento de que sempre foi uma companhia pertencente a apenas uma única entidade familiar, o que equivale dizer que era, de fato, de capital fechado a novos investidores. Desta forma, ainda que por caminho diverso do que o até agora percorrido, se a Instrução 361 fosse corretamente observada e bem aplicada pelos profissionais envolvidos, teríamos, de fato, todas as condições necessárias para a dispensa da OPA, ou para a sua realização de forma diferenciada*”.

34. Por fim, os Acusados informaram que, concomitantemente à apresentação da defesa, estariam apresentando proposta de termo de compromisso e pleitearam a “*improcedência do feito, por falta de justa causa, uma vez que há previsão legal para a dispensa da OPA, ou para a sua realização por procedimento diferenciado, o qual ainda não foi apreciado*”.

VI – Termo de Compromisso (fls. 141-144).

35. Juntamente com a defesa, os Acusados apresentaram proposta de termo de compromisso com as seguintes condições:

- a) realização da OPA referente à aquisição do controle acionário da CELM, pelo valor de R\$15,51 por ação, com a publicação de editais em dois jornais de grande circulação visando a dar a publicidade adequada aos minoritários, comprometendo-se, ainda, a envidar esforços com o

objetivo de identificar os endereços dos acionistas minoritários a fim de enviar correspondência com igual conteúdo dos editais publicados;

- b) pagamento à CVM do valor total de R\$10.000,00, em cinco parcelas; e
- c) compromisso, por parte de Carlos Alexandre Bonatti, de não atuar no mercado de capitais por período não inferior a 10 anos, tempo em que não atuaria por si, ou por pessoa jurídica que viesse a compor, em qualquer segmento relacionado ou submetido às normas da CVM.

36. Instada a se manifestar sobre a proposta, a PFE apontou que não seria exigível, no caso, a cessação da prática ilícita (art. 7º da Deliberação nº 390/01), considerando a natureza das infrações, em tese já executadas e exauridas quanto ao resultado. Quanto à correção das irregularidades com indenização dos prejuízos, entendeu que se daria no caso concreto com a realização da OPA, nos termos da Deliberação nº 361/02, como proposto pelos Acusados.

37. Entretanto, considerou que as circunstâncias atuais inviabilizariam sua operacionalização, uma vez que a OPA direciona-se exclusivamente a companhias abertas, nos termos do art. 1º da Instrução CVM nº 361/02, e o registro de companhia aberta da CELM teria sido cancelado de ofício pela SEP.

38. Além disso, teria, na visão da Procuradoria, um impeditivo de ordem prática, tendo em vista a dificuldade da Companhia em localizar os acionistas minoritários da CELM, tendo passado mais de quatro anos da transferência do controle, ocorrido em 07.01.2009.

39. Ressaltou a PFE, ainda, que em razão do dano ao regular funcionamento do mercado e à ordem jurídica, mostrar-se-ia compatível com a disciplina normativa e os precedentes da CVM, a exigibilidade de um valor indenizatório em favor da autarquia, a fim de mitigar os efeitos indesejáveis da violação; coibindo, assim, ocorrências futuras, tendo em vista seu caráter exemplar.

40. Recebido o parecer da PFE, o Comitê de Termo de Compromisso ("Comitê") enviou aos Acusados as seguintes ponderações sobre a proposta apresentada: (i) tecnicamente não haveria mais que se falar em realização de uma OPA, visto que o instrumento seria utilizado somente por companhias abertas e, nessa linha, a questão deveria ser tratada como um ressarcimento ou indenização que, na visão do Comitê, deveria ser direcionada aos ex-acionistas minoritários; (ii) para avaliar a viabilidade de aceitação da proposta, seriam necessárias maiores informações, a fim de alcançar resultados práticos, uma vez que os fatos que deram origem ao processo ocorreram há mais de quatro anos; (iii) e, por fim, perguntou aos proponentes qual seria o valor estimado para ressarcimento aos ex-acionistas e quantos seriam (fls. 165-166).

41. Em resposta (fls. 169-175), o advogado dos Acusados afirmou que teriam sido feitos todos os esforços possíveis para localizar e identificar os minoritários; entretanto, não havia muitos registros ou documentos que pudessem atribuir 100% de certeza. Apesar desse fato, uma vez identificada a maioria dos acionistas, entende que a publicação em jornais de grande circulação seria suficiente para sanar o problema.

42. O processo então retornou à SRE e foi enviado ofício²¹ aos Acusados, solicitando os seguintes esclarecimentos:

- i. comprovar o valor por ação efetivamente pago aos controladores;*
- ii. informar como foram obtidos os nomes dos acionistas minoritários da CELM, apresentando documentação comprobatória;*
- iii. esclarecer, detalhadamente, quais seriam os 'esforços para localizar os endereços dos acionistas minoritários' mencionados na proposta em questão.*

43. Em resposta (fls. 181-183), os Acusados esclareceram que não teria sido feito *"o pagamento de um único centavo pela aquisição das ações dos antigos controladores. Sendo certo ainda que, na ocasião, as ações da Celm eram listadas em R\$15,51"*. Afirmam que teria sido pactuado que o eventual pagamento dependeria do levantamento completo do real passivo da empresa e que o preço ajustado teria sido de R\$1,710 milhão por um total de 110.216 ações ordinárias nominativas (valor unitário de R\$15,51).

44. Afirmam que após a transferência das ações teria sido feito um levantamento e identificado um passivo exigível superior a R\$23 milhões, sendo que tal apuração já demonstraria que as ações não teriam valor comercial que justificasse o desembolso de qualquer quantia. Portanto, não seria possível atender à solicitação feita no ofício, uma vez que *"não há como comprovar o que nunca existiu"*.

45. Sobre a identificação dos minoritários, após assumir o controle da sociedade, teria sido constada a inexistência, ou desaparecimento, de vários documentos e, nesse sentido, a única informação acerca dos dados dos acionistas minoritários seria uma tabela encontrada em um dos computadores do departamento financeiro da CELM, sendo, segundo os Acusados, desconhecida a existência de qualquer outro controle ou listagem que pudesse indicar com precisão quem seriam os minoritários.

46. Por fim, quanto aos esforços que seriam feitos para localizá-los, esclareceram os Acusados que seria formado *"um grupo de trabalho, que inicialmente irá realizar pesquisas nos diversos cadastros disponíveis pela internet, visando a localizar e atualizar o endereço dos sócios. A ação terá divulgação na empresa, anúncio em mídias diversas, publicação de edital e envio de correspondências com AR para os sócios cujos respectivos endereços forem conhecidos"*.

47. Após analisar a resposta dos Acusados, a SRE ponderou que como *"os acusados não encaminharam documento hábil a comprovar o valor por ação efetivamente pago aos antigos controladores, manifestamo-nos desfavoravelmente à aceitação da proposta"* (fls. 189-190).

48. O Comitê, em seu parecer final, propôs ao Colegiado a rejeição da proposta conjunta apresentada (fls. 203-211). Explicou que não sendo viável a correção da irregularidade por meio da realização de OPA, somente seria possível avaliar proposta que contemplasse ressarcimento aos ex-acionistas minoritários da CELM. Como os proponentes não teriam logrado êxito em comprovar os valores efetivamente pagos aos controladores, assim como não teria sido enviada uma relação fidedigna nos minoritários, entendeu que o elevado grau de incerteza nos dados obtidos teria tornado a celebração do termo de compromisso inconveniente e inoportuna.

49. O Colegiado, em reunião realizada em 02.06.2015, deliberou, por unanimidade, pela rejeição da proposta, acompanhando o entendimento constante do parecer do Comitê.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor Relator

¹ Fls. 114-123.

² Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

³ Art. 29. A OPA por alienação de controle de companhia aberta será obrigatória, na forma do art. 254-A da Lei 6.404/76, sempre que houver alienação, de forma direta ou indireta, do controle de companhia aberta, e terá por objeto todas as ações de emissão da companhia às quais seja atribuído o pleno e permanente direito de voto, por disposição legal ou estatutária.

⁴ De acordo com o termo de transferência nº 59, no dia 07.01.2009 foram transferidas 87.651 ações ordinárias de emissão da Companhia de P.A.M. para a Hoje Participações; na mesma data, também consta a transferência de 21.967 ações ordinárias da CELM de E.M.A.M. para a Hoje Participações (termo nº 60).

⁵ Ofício GAE 1676/09, de 08.07.2009 (fls. 19).

⁶ Resposta às fls. 20-21 (não consta data no documento).

⁷ Ofício/CVM/SRE/GER-1/nº 109/2010 de 03.02.2010 (fl. 23).

⁸ Ofício/CVM/SRE/GER-1/Nº 189/2010 de 1.03.2010 (fls. 38-39) e Ofício/CVM/SRE/GER-1/Nº 1199/2010 de 08.09.2010 (fls. 48), tendo a Companhia recebido multa cominatória no valor de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), conforme documentos acostados às fls. 53-54.

⁹ Ofício/CVM/SRE/nº 1163/2011 de 25.10.2011 (fl. 59).

¹⁰ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado: (...)

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

¹¹ Correspondência protocolada na CVM em 24.11.2011 (fl. 67).

¹² Ofício/CVM/SRE/Nº 510/2012, de 10.08.2012 (fls. 83-84).

¹³ Ofício/CVM/SRE/Nº 518/2012, de 17.08.2012 (fls. 88-89).

¹⁴ Item 21 do termo de acusação (fls. 118).

¹⁵ A SRE destacou que essas seriam as AGEs mais recentes, disponíveis no IPE, anteriores à operação realizada com a Hoje Participações.

¹⁶ A SRE ressaltou que o IAN de 2006 é mais atual disponibilizado pela CELM, que teve o seu registro de companhia aberta cancelado de ofício pela SEP em 04.01.2011, em virtude da situação de inadimplência na entrega de informações periódicas.

¹⁷ O termo de acusação destaca que “a responsabilização de diretores por condutas atribuídas primariamente às sociedades que dirigem não é novidade no âmbito da CVM. Com efeito, o Colegiado, no julgamento do PAS RJ 2005/6924, com o voto condutor do então Presidente Marcelo Trindade, decidiu que ‘... tanto o Banco [X] quanto seu Diretor [Y] devem ser apenados, o primeiro como agente da conduta indevida (...), e o segundo por omissão em seu dever de atuar, na qualidade de diretor responsável pelo Departamento de Mercado de Capitais, para o fim de que a atuação de seus subalternos se desse de maneira adequada às normas (...)’”.

¹⁸ Sobre esse ponto, a Acusação pondera que “De acordo com os Termos de Transferência de Ações, a Hoje teria adquirido do Sr. P.A.M. e da Sra. E.M.A.M. um total de 109.618 ações ordinárias de emissão da CELM e não 110.216 ações. Se considerado esse quantitativo, a OPA atingiria o montante de R\$ 79.187,85. Nos cálculos acima foi considerado o preço de R\$ 15,51 por ação”.

¹⁹ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele

imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

²⁰ PARECER/Nº 65/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

²¹ Ofício/CVM/SRE/Nº 601/2013, de 23.12.2013 (fls. 173).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2012/13740

Acusados: Hoje Participações Investimentos S/C Ltda.
Carlos Alexandre Bonatti

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade pela não realização de oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle, em infração ao disposto nos artigos 254-A, da Lei nº 6.404/76, e 29, da Instrução CVM nº 361/02, em decorrência da aquisição do controle acionário da CELM – Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários em 21.02.2013 (“Acusação”, ou “SRE”), em face de Hoje Participações Investimentos S/C Ltda. (“Hoje Participações”) e Carlos Alexandre Bonatti (conjuntamente denominados “Acusados”), para apurar a eventual responsabilidade pelo descumprimento do art. 254-A¹ da Lei nº 6.404/76 e do art. 29² da Instrução CVM nº 361/02, por não ter realizado a Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”) obrigatória, em decorrência da aquisição do controle acionário da CELM – Companhia Equipadora de Laboratórios Modernos (“CELM, ou “Companhia”).

2. Como visto no relatório, aduz a Acusação que, em 07.01.2009, a Hoje Participações teria se tornado controladora da CELM, mediante a aquisição de 110.216 ações ordinárias de emissão da companhia dos acionistas P.A.M. (87.651 ações), E.M.A.M. (21.967 ações), V.A.M. e I.A.M.³, representativas de 95,014% do capital social, sem a realização da OPA.

3. Para a SRE, não haveria dúvidas de que P.A.M. era acionista controlador da CELM antes da operação, pois (i) era proprietário de 87.651 ações, com participação de 76,56% do capital votante da CELM, anteriormente à transferência de suas ações à Hoje Participações⁴; (ii) foi eleito nas assembleias gerais extraordinárias realizadas em 11.05.2004 e de 15.12.2006 como presidente do Conselho de Administração da CELM⁵, e (iii) o acionista era indicado no IAN da Companhia de 2006 como controlador, por já possuir, àquela época, 52% das ações ordinárias de sua emissão.

4. Os Acusados, por sua vez, sustentaram, inicialmente, que não triam infringido a legislação, uma vez que, antes da operação com a Hoje Participações, “não existia uma estrutura de poder consolidada, seja por não haver um acionista majoritário, seja em razão de não existir um bloco de acionistas vinculados por acordo de acionistas, com a finalidade de exercerem, com exclusividade, o domínio sobre a atividade empresarial da Sociedade! (fls. 34).

5. Posteriormente, ao apresentarem defesa, afirmaram que não teriam experiência com o mercado de capitais e que, após orientação profissional, teriam sido informados que a OPA não seria necessária. Destacaram que se a CVM

entendesse pela obrigatoriedade de realização da OPA, eles assim procederiam. Ressaltaram, ainda, que não teriam agido com má-fé, ou com intenção de prejudicar os acionistas da Companhia, e que triam tentado identificar e contatar os demais acionistas, sem êxito.

6. Neste ponto, antes de adentrar no mérito, importa traçar um brevíssimo histórico acerca do direito de venda conjunta (ou *tag along*) dos acionistas minoritários no direito pátrio. Introduzida no ordenamento jurídico com a promulgação da Lei nº 6.404/76, a redação original do art. 254 previa o direito de saída conjunta aos minoritários, pelo mesmo preço pago ao alienante das ações que lhe asseguravam o poder de controle. Estabelecia, ainda, que a alienação do controle da companhia aberta dependeria de prévia autorização da CVM, que deveria *"zelar para que seja assegurado tratamento igualitário aos acionistas minoritários, mediante simultânea oferta pública para aquisição de ações"*⁶.

7. Anos depois, o art. 6º da Lei nº 9.457/97 revogou expressamente o art. 254 e os parágrafos do art. 255, que previam a aplicação do *tag along* às companhias com controle estatal, tendo como justificativa adaptar a lei "à nova realidade da economia brasileira" à época, e "incentivar o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil (...)"⁷

8. Especificamente com relação à exclusão do *tag along*, a justificativa do projeto defendia que *"apenas na aparência esse dispositivo favorece o acionista minoritário. Na prática, por inibir processos de saneamento e capitalização em que a alienação do controle é indispensável, o dispositivo contribui para inviabilizar definitivamente empresas em dificuldade e, assim, gerar prejuízos que recaem sobretudo sobre os minoritários"*.

9. A par de tal justificativa, sobreveio um forte movimento para que os direitos econômicos dos minoritários fossem fortalecidos, o que ocorreu com a grande reforma introduzida pela Lei nº 10.303/01. Assim, foi reincorporado à Lei nº 6.404/76, por meio do art. 254-A (abaixo transcrito), o direito de venda conjunta pelos minoritários em caso de transferência de controle, com algumas alterações em relação à redação original, como o pagamento de 80% do valor pago aos alienantes detentores do controle (o texto anterior estabelecia igual valor) e a definição expressa dos destinatários da oferta.

Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta, somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva, ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago com ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

§1º - Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta, ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade.

§2º - A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais.

§3º - Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata o caput.

§4º - O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle.

10. Ressalta-se que, apesar de o novo texto legal ter atribuído um valor diferenciado às ações integrantes do bloco de controle, diferença denominada por alguns doutrinadores⁸ “*ágio*”, ou “*prêmio de controle*”, a alteração legislativo veio a restabelecer direito de significativa importância para proteção dos acionistas minoritários e, em última análise, para o próprio desenvolvimento do mercado de capitais⁹.

11. Trata-se de uma “*socialização parcial do prêmio de controle*”¹⁰, que “exige do potencial adquirente um investimento que engloba, além do preço de compra das ações do bloco de controle, montante necessário para adquirir as ações dos minoritários que optarem por aceitar a oferta. Em geral, implica redução do valor global que seria pago ao controlador alienante pelo adquirente, caso este não tivesse que lançar a oferta de compra aos minoritários¹¹⁻¹²”.

12. Na mesma linha, o Colegiado da CVM já se manifestou ao afirmar que a finalidade do art. 254-A seria “*conferir a possibilidade de uma “compensação” à quebra da estabilidade do quadro acionário, permitindo que os acionistas minoritários alienem as suas ações por preço determinado em lei (que pode ser aumentado pelo estatuto social), quando essa estabilidade for perturbada*”¹³”.

13. Com a reintrodução do direito de venda conjunta em 2002, a CVM editou a Instrução CVM nº 361, que veio disciplinar o procedimento aplicável às ofertas públicas de aquisição de ações de companhia aberta, sendo a oferta pública por alienação de controle tratada nos artigos 29 e 30. No art. 29 estão previstos os principais requisitos e elementos da obrigação, transcritos a seguir:

Art. 29. A OPA por alienação de controle de companhia aberta será obrigatória, na forma do art. 254-A da Lei 6.404/76, sempre que houver alienação, de forma direta, ou indireta, do controle de companhia aberta, e terá por objeto todas as ações de emissão da companhia às quais seja atribuído o pleno e permanente direito de voto, por disposição legal, ou estatutária.

§1º - A OPA deverá ser formulada pelo adquirente do controle, e o seu instrumento conterá, além dos requisitos estabelecidos pelo art. 10, as informações contidas na notícia de fato relevante divulgada quando da alienação do controle, sem prejuízo do disposto no inciso I do §1º do art. 33, se for o caso.

§2º - O requerimento de registro da OPA de que trata o caput deverá ser apresentado à CVM no prazo máximo de 30 dias, a contar da celebração do instrumento definitivo de alienação das ações representativas do controle, quer a realização da OPA se constitua em condição suspensiva, quer em condição resolutiva de alienação.

§3º - O registro da OPA pela CVM implica na autorização da alienação do controle, sob a condição de que a oferta pública venha a ser efetivada nos termos aprovados e prazos regulamentares.

§4º - Para os efeitos desta instrução, entende-se por alienação de controle a operação, ou o conjunto de operações, de alienação de valores mobiliários com direito a voto, ou neles conversíveis, ou de cessão onerosa de direitos de subscrição desses valores mobiliários, realizada pelo acionista controlador, ou por pessoas integrantes do grupo de controle, pelas quais um terceiro, ou

um conjunto de terceiros, representando o mesmo interesse, adquira o poder de controle da companhia, com o definido no art. 116 da Lei nº 6.404/76.

§5º - Sem prejuízo da definição constante do parágrafo anterior, a CVM poderá impor a realização de OPA por alienação de controle sempre que verificar ter ocorrido a alienação onerosa de companhia aberta. (grifo nosso).

14. Para a análise do caso concreto, deve ser verificada a ocorrência da hipótese de incidência da OPA, que é *"a alienação de forma direta, ou indireta, do controle de companhia aberta"*. Sob essa ótica, a tese sustentada pela defesa, de que não houve transferência de controle, não merece prosperar.

15. Conforme apontado pela Acusação, foram transferidas à Hoje Participações 110.216 ações ordinárias da CELM, representativas de 95,014% do seu capital social, sendo que 75,56% pertenciam a P.A.M. e 18,94% a E.M.A.M., estando 94,5% das ações, portanto, nas mãos desses dois acionistas, que eram, de acordo com os últimos documentos atualizados antes da operação, presidente e vice-presidente do conselho de administração.

16. Além disso, constava no IAN da Companhia do ano de 2006 a indicação de P.A.M. como controlador da CELM. Essas informações já bastam para afirmar que a família M., especialmente P.A.M., controlava a CELM, afirmação, inclusive, feita pela própria defesa ao afirmar que *"o controle da empresa estaria concentrado em uma única entidade familiar (família M.), levando ao cristalino entendimento de que sempre foi uma companhia pertencente a apenas uma única entidade familiar, o que equivale dizer que era, de fato, de capital fechado a novos investidores"*.

17. A própria Companhia, ao responder os questionamentos da BM&F Bovespa feitos em 08.07.2009 sobre a operação com a Hoje Participações, afirmou que: *"em oportuna oferta pública de compra de ações e em cumprimento ao disposto no art. 254-A da Lei nº 6.404/76, a Empresa pretende adquirir, à vista, as ações que circulam no mercado, oferecerá aos demais acionistas minoritários que, juntos, representam 4,986% do capital social da Companhia, o valor previsto e assegurado no referido artigo da Lei que rege as sociedades de capital aberto"* (fls.21).

18. Portanto, resta incontroverso que a operação de transferência das ações da CELM por acionistas detentores de 95,014% das ações, dentre elas P.A.M., caracterizou alienação de controle de companhia aberta para fins de cumprimento do disposto nos artigos 254-A e 29 da Lei nº 6.404/76, e da Instrução CVM nº 361/02, respectivamente.

19. Pela mesma razão, não prospera o argumento de que teria havido uma aquisição originária de controle pela Hoje Participações, conforme defendido pelo parecer jurídico juntado aos autos, que alegou que a CELM *"constituía companhia na qual não existia estrutura de poder consolidada, seja por não haver um acionista majoritário, seja em razão de não existir um bloco de acionistas vinculados por um acordo de acionistas, com a finalidade de exercerem, com exclusividade, o domínio sobre a atividade empresarial da sociedade"*.

20. Como já mencionado, com a transferência de 95,014% das ações com direito de voto de emissão da CELM, houve, de fato, a alienação do controle da companhia, caracterizando, assim, uma aquisição derivada do controle, e não originária, como quiseram fazer crer os Acusados, e, portanto, conforme entendimento já pacificado, enseja-se a aplicação do art. 254-a

21. Noutro vértice, com relação à autoria da infração cometida, assiste razão à Acusação ao responsabilizar a Hoje Participações, adquirente do controle acionário, para quem o comando das normas infringidas remete a obrigação. Contudo, tenho que a expressão “adquirente”, contida nos já mencionados artigos 254-A da Lei nº 6.404/76 e 29 da Instrução CVM nº 361/02, não compreende a figura do administrador, e, tampouco, recai sobre o sócio de sociedade de responsabilidade limitada as obrigações e os deveres fiduciários dos administradores sob supervisão desta Comissão de Valores Mobiliários.

22. No tocante à dosimetria da pena, será levada em consideração a situação financeira da companhia à época¹⁴ e, além disso, o fato de a Hoje Participações deter significativa participação, equivalente a 95,014% do capital social da CELM, restando, assim, uma pequena quantidade de ações a ser adquirida em eventual oferta de aquisição¹⁵. Assim, a OPA seria, ao menos em tese, elegível ao procedimento diferenciado previsto no art. 34 da Instrução CVM nº 361/02, em vista das mencionadas situação financeira e elevada concentração de ações.

23. Há de se destacar, por fim, a importância, para assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado e a devida proteção aos minoritários, da regra aqui analisada e do seu efetivo cumprimento, cuja violação é consideração infração grave nos termos do art. 41 da Instrução CVM nº 361/02. O descumprimento da obrigação de realizar oferta pública de aquisição das ações dos minoritários votantes é, de fato, muito grave, pois, além de ter o potencial de causar prejuízos financeiros, mina a confiança dos investidores e diminui a sua disposição para investir no mercado de capitais.

24. Eventuais prejuízos podem (e devem) ser discutidos no âmbito do judiciário, instância competente para dirimir questões indenizatórias, mas, cabe a esta Autarquia, visando a atingir as finalidades que lhe foram conferidas nos termos do art. 4º da Lei nº 6.385/76, reprimir esse tipo de conduta e punir os seus responsáveis.

25. Em face de todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, voto:

- (a) Pela absolvição de Carlos Alexandre Bonatti; e
- (b) Pela condenação da Hoje Participações Investimentos S/C Ltda. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 100.000,00, por infração ao disposto no art. 254-A da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 29 da Instrução CVM nº 361/02.

É como voto.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

¹ A alienação, direta, ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

² A OPA por alienação de controle de companhia aberta será obrigatória, na forma do art. 254-A da Lei 6.404/76, sempre que houver alienação, de forma direta ou indireta, do controle de companhia aberta, e

terá por objeto todas as ações de emissão da companhia às quais seja atribuído o pleno e permanente direito de voto, por disposição legal ou estatutária.

³ Não foram informadas as quantidades de ações transferidas individualmente pelos acionistas V.A.M. e I.A.M.

⁴ Essa participação foi calculada pela Acusação, levando em conta que os Acusados afirmaram que a Hoje Participação teria adquirido 110.216 ações representativas de 95,014% do capital social, o que levaria, por mero cálculo aritmético, ao total de 116.000 ações ordinárias da Companhia, quantitativo confirmado pelo IAN de 2006 (fls. 46).

⁵ Assembleias gerais da Companhia mais recentes antes da operação realizada com a Hoje Participações (07.01.2009), em que foi deliberada eleição de membro do conselho.

⁶ Redação original do art.254, *caput*, e §1º, da Lei nº 6.404/76, revogados pela Lei nº 9.457/97.

⁷ Conforme consta na “justificação” do Projeto de Lei nº 1.564, de 1996 (Projeto Kandir), que, posteriormente, se transformou na Lei nº 9.457/97, integrante do Processo de tramitação do projeto, disponível em

HTTP:WWW.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?jsessionid=2EC8BDA89E5B530142B408E8143A6C06.proposicoesWeb1?codteor=1139&filename=Dossie+-PL+1564/1996.

⁸ EIZIRIK, Nelson;Gaal, Ariádna B.;Parente, Flávia;Henriques, Marcus de Freitas. Mercado de capitais – regime jurídico, 3ª Ed. Ver. E ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 6007. ANDREZO, Andrea Fernandes. Alienação de Controle de Companhia Aberta e a Recente Reforma da Legislação Societária. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, vol. 130, abr./jun.2003, p.164.PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de controle de companhia aberta. São Paulo, Quartier Latin, 2012, p.25-26.

⁹ Há estudos no sentido de quanto maior a proteção aos investidores, maior a disposição desses em financiar as companhias, porque haveria menor risco de expropriação por parte de administradores e de controladores. As companhias, por sua vez, teriam mais incentivos a emitir valores mobiliários quando os investidores estão dispostos a pagar mais por eles (in ANDREZO, Andrea Fernandes. Op. cit. p. 160-161).

¹⁰ PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de controle de companhia aberta. São Paulo, *Quartier Latin*, 2012, p. 38.

¹¹ PENNA, Paulo Eduardo, Op. Cit., p. 47.

¹² Uma das razões para a existência desse *spread* seria a insuficiente proteção dos interesses dos minoritários, que resultaria na apropriação, pelos controladores, dos chamados *private benefits of control* (i.e., acesso a empréstimos subsidiados, uso de bens da sociedade para fins particulares etc.); ou seja, se aceita pagar um sobrepreço pelo controle de certas companhias em razão da expectativa de que esse valor será recuperado por meio dessa expropriação (in EIZIRIK, Nelson, Mercado de Capitais – Regime Jurídico – 3ª edição, Renovar, p.608).

¹³ Trecho extraído do voto do diretor-relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, proferido no âmbito do PAS CVM nº RJ2005/4069, o qual foi acompanhado pelos demais membros do Colegiado.

¹⁴ Os acusados juntaram documentos emitidos em 2013, por meio da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, em que constam débitos em nome da CELM relativos a débitos de ICMS, em autuação da ordem de 27 milhões de reais.

¹⁵ Considerando uma oferta de 5.784 ações a R\$15,51, a OPA atingiria um valor de R\$71.767,87 (fls.122).